

1522530-84.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522530-84.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522530-84.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL HERRERA DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

Recebo a conclusão somente nesta data, em razão de retorno de afastamentos autorizados.

RAFAEL HERRERA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, segundo apurado, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 21h20min, na Rua Helvetia, na altura do nº 55, Santa Cecília, nesta Capital, trazia consigo, para fim de tráfico, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 12 (doze) porções de "crack", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, com peso líquido de 439,9 gramas (laudo pericial nº 306.620/2021 - fls. 10/12).

A denúncia foi recebida (fls. 73/75), o réu foi citado e notificado (fls. 88), sendo apresentada a resposta à acusação em audiência, durante a qual foram ouvidos dois policiais e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou pela absolvição do acusado alegando, em suma, insuficiência probatória. Subsidiariamente, em eventual caso condenação, pugnou pela fixação da pena base em seu mínimo legal; compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa; fixação do regime inicial menos gravoso e, ainda, possibilidade de apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegalidade da abordagem e, consequente, prisão em flagrante do acusado pela Guarda Municipal.

De fato, muito embora não tenha a Guarda Municipal poder de polícia (art. 144, §8º, da Constituição Federal), nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal:

"qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Logo, qualquer pessoa e ainda mais os agentes públicos, incluindo os guardas civis metropolitanos estão aptos a efetuar a prisão em flagrante ao vislumbrar qualquer indivíduo cometendo crime, segundo preceitua a norma processual.

No caso em tela, a abordagem do réu se deu no momento em que ele apresentou nervosismo ao tentar ingressar no "fluxo da Cracolândia", local notoriamente conhecido pelo comércio de drogas, onde não é raro que os agentes municipais abordem pessoas em flagrante tráfico de entorpecentes, situação que não indica qualquer desvio de função dos agentes públicos, já que, realizada a detenção do acusado, seguiu-se rigorosamente à apresentação perante autoridade policial e judicial para que fossem realizados os devidos trâmites legais.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, § 8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal, em seu art. 301 do CPP, disciplina que 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'. (...) 4. Ordem denegada." (HC 109105 / SP - Quinta turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - Julgado em 23/02/2010)

Superada a preliminar, verifico que a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão das drogas, pelo laudo de constatação de substâncias entorpecentes (fls. 10/12), corroborado pelo o laudo pericial definitivo, positivo para Cocaína, fotografia de apreensão dos entorpecents, (fls. 13), bem como pela prova oral colhida em solo policial e em juízo.

Ouvida em juízo, a testemunha e a guarda civil metropolitano Priscilla Muller Parra narrou que estava em patrulhamento pela rua Helvétia com seu parceiro de farda, quando o acusado passou próximo a eles com um volume na região da cintura, o que chamou sua atenção. Informou, ainda, que o acusado ficou muito nervoso quando avistou a viatura. Diante de tais fatos, procederam a abordagem. Em busca pessoal, identificaram que o volume se tratava de pedras de crack, que estavam presas ao corpo do acusado por fita isolante. Indagado, o réu informou que as drogas não lhe pertenciam, apenas faria o transporte delas para dentro do "fluxo da Cracolândia", como pagamento de uma dívida de R\$ 5.000,00, mas não identificou quem seria o dono da droga.

No mesmo sentido, a testemunha e guarda civil metropolitano Damião Alberto De Sousa Ferreira, ouvida em juízo, narrou que, na data dos fatos, o acusado tentou ingressar no "fluxo da Cracolândia" de forma apressada e aparentando muito nervosismo. Diante de tais fatos, abordaram o réu e, em revista pessoal, localizaram porções de drogas afixadas nas costas dele por meio de fita isolante. Inicialmente o réu negou que se tratavam de entorpecentes, mas em análise mais detida identificaram que se tratava de "crack". Informou que foram apreendidas com o réu 12 porções de "crack", sendo que cinco dela eram tabletes grandes. Indagado, o réu informou aos guardas que tinha uma dívida de R\$ 5.000,00 com os traficantes e que estava fazendo o transporte das drogas como forma de pagamento de parte da dívida. No mais, o acusado disse que era usuário de drogas.

O réu, por sua vez, nas duas oportunidades em que foi ouvido, manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante de todos os elementos constantes nos autos, laudo pericial com resultado positivo para cocaína, corroborados pelos depoimentos dos dois policiais, a condenação é medida que se impõe.

Há que se asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem agentes da guarda civil metropolitana, nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos dessas testemunhas, apenas pela sua condição de agente público, agindo para garantir a segurança pública, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração destes depoimentos somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu de patrulhamento ostensivo de rotina, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação ao acusado, e, para espantar qualquer dúvida em relação à eventual suspeição por parte dos policiais, o réu, em nenhum momento alegou haver qualquer tipo de perseguição contra o acusado por parte da polícia.

Confira-se: Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Por outro lado, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, modo como estavam "escondidas" por baixo das vestes do acusado, bem como o local de apreensão, em região popularmente conhecida como "Cracolândia", já são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido. (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, de acordo com a certidão de fls. 30/31, tendo em vista que foi condenado definitivamente pelo delito de roubo na 1ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda (Autos nº 1515765-34.2020.8.26.0228.). Por outro lado, o acusado foi por várias vezes processado perante a Vara da Infância e Juventude por ato infracional (fls. 32/33), o que demonstra que tem personalidade voltada para o crime. Assim, não lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, devendo a sua pena base ser aumentada em 1/6, chegando-se ao patamar de 05 anos, 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, respeitado entendimento diverso, há que se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do Corona vírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Neste ponto, respeitado posicionamento em contrário, para esta magistrada, é notório que o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento

social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. O réu, contudo era menor de 21 anos na data do cometimento do delito, consoante informações de fls 14 e neste caso a pena não deve ser alterada, já que atenuante e agravante se compensam. Presente no caso também a agravante da reincidência acima apontada e assim sendo, a pena deve ser agravada em 1/6, chegando ao patamar de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que o acusado é reincidente e possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 32/33), não há que se falar em aplicação do disposto no do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, já que comprovado está que o réu se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido, conforme já decidido pelos Tribunais Superiores:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no RESp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. In casu, a instância antecedente justificou a não incidência da minorante com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que o histórico infracional do recorrente, com registro de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, não deixa dúvida de sua notória progressão criminosa. Cumpre registrar, ainda, que com ele foram apreendidos 51,7 g de maconha, 21,8 g de cocaína e 7,7 g de crack. 4. Vale anotar que "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 28/8/2020). 5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1822052/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021) - g.n.

Nesse particular, não há falar em bis in idem pelo simples fato de a reincidência servir agora como fundamento para agravar a pena e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, como vem decidindo nossas cortes superiores.

Isto porque, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado". Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência

quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (TJSP, Apel. Crim. nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro). Não havendo nos autos provas da condição econômica do acusado, o dia multa será fixado no mínimo legal estabelecido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão; e 680 dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e ainda em razão da reincidência, o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado.

Não se pode esquecer que o crime em tela, é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Outrossim, levando-se em conta a quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência do réu, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, e para a garantia da aplicação da lei penal.

Como se sabe o crime de tráfico é o que sustenta inúmeras facções criminosas que com o dinheiro arrecado pela venda de drogas adquirem armamento de alto calibre e praticam diversos outros delitos colocando em risco toda a sociedade.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Assim, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado Cg2225/18, determino a destruição de todas as drogas apreendidas, inclusive eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA